

1501467-55.2020.8.26.0319

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Jose Luis Pereira Andrade

Comarca: Lençóis Paulista

Foro: Foro de Lençóis Paulista

Vara: 3ª Vara Cumulativa

Data de Disponibilização: 27/05/2022

... de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lençóis Paulista

Foro de Lençóis Paulista

3ª Vara Cumulativa

Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501467-55.2020.8.26.0319 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501467-55.2020.8.26.0319

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL DA SILVA ALVES DE JESUS

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Jose Luis Pereira Andrade

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de RAFAEL DA SILVA ALVES DE JESUS, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, ao argumento de que o réu teria se associado com outros dois indivíduos não identificados, sendo um destes - e líder do grupo - conhecido pela alcunha de "Nigeriano", com o fim de praticar crimes contra o patrimônio, especialmente estelionatos. Aduziu o Parquet que Nigeriano tinha a função de ir ao interior do Estado para receber cartões bancários e senhas das futuras vítimas, sobretudo idosos; ao passo que o outro comparsa se incumbia de telefonar aos correntistas para obter seus dados pessoais e convencê-los de que haviam sido vítimas de um golpe inexistente e que precisariam entregar seus cartões com as respectivas senhas a um suposto agente da Caixa Econômica Federal denominado "Tiago Silva". Sustentou tocar ao réu a função de ir ao endereço dos correntistas para recolher os cartões. Alegou que, em 01/07/2020, por volta das 16h00min, na Rua Odila Joana Paccola Ludovico, 32, Lençóis Paulista, um dos agentes telefonou para Norma Lini, então com 73 anos de idade, e a teria enganado, convencendo-a de que teria havido um saque fraudulento em sua conta poupança junto à CEF no importe de R\$ 1.500,00 e

persuadindo-a a fornecer as senhas dos seus cartões administrados pelas Lojas Pernambucanas e pelo Banco Sicoob, dizendo-lhe que posteriormente um agente da CEF iria até a sua casa para recolher os indigitados cartões, além de uma carta de próprio punho para viabilizar a restituição do falso saque. Asseverou que, em seguida, o réu teria ido até a casa da vítima, passando-se por "Tiago Silva", e recolheu os cartões, e, na posse deles, o grupo teria despendido R\$ 2.750,99 com o cartão das Lojas Americanas e R\$ 500,00 com o cartão do Banco Sicoob, totalizando um prejuízo à vítima de R\$ 3.250,99. Informou que, durante as investigações, a Polícia Civil encontrou significativas semelhanças com procedimento inquisitorial instaurado em Jaú/SP, resultando nos autos da ação penal nº 1501155-33.2020.8.26.0302, tendo a Norma Lini sido chamada para realizar o reconhecimento fotográfico com o réu, o que teria ocorrido sem qualquer dúvida. Requereu, assim, que o réu fosse incurso no tipo penal previsto no art. 171, § 4º, c/c a agravante do art. 61, II, j, ambos do Código Penal, com a respectiva condenação. A denúncia, de fls. 67/70, está acompanhada do inquérito policial e documentos de fls. 01/65, de que consta o termo de representação à fl. 20. No ato do oferecimento da denúncia, o Ministério Público afirmou não ser o caso de oferecimento de acordo não persecução penal. Ainda, pediu para que se oficiassem à Lojas Pernambucanas e ao Banco Sicoob para que fornecessem as faturas dos cartões da vítima referentes aos meses de junho a setembro de 2020. Em decisão de fl. 72, a denúncia foi recebida, sendo deferido o pedido de ofício às empresas. O Banco Siccob afirmou, à fl. 107, não ter a vítima no quadro de seus clientes, enquanto as Lojas Pernambucanas apresentou os documentos solicitados às fls. 114/121. Citado, o réu, mediante defensor dativo, apresentou resposta escrita à fl. 127, dizendo-se inocente e preferindo manifestar-se sobre o mérito da acusação com maior acuidade oportunamente. Foi noticiado, à fl. 135, o falecimento da vítima ocorrido em 24/05/2021 (com a certidão de óbito juntada às fls. 140/141). Às fls. 136/139, foi ratificado o recebimento da denúncia, sendo designada audiência virtual de instrução para o dia 15/02/2022. O Ministério Público, à fl. 145, pugnou pela substituição da oitiva da vítima pela de seus filhos, com o que concordou a Defesa à fl. 183, sendo deferido o pedido à fl. 202. O réu constituiu defensor próprio (fls. 231/232). Na audiência, foram colhidos os depoimentos de quatro testemunhas e, com o aval da Defesa, o interrogatório, considerando-se que uma testemunha policial não compareceu justificadamente. Em seguida, foi determinada nova conclusão para a oitiva da testemunha ausente (fls. 234/236). A audiência em continuação ocorreu em 26/04/2022, na qual foi colhido o depoimento da testemunha em questão. Após, foi determinado o encerramento da instrução, oportunizando-se às partes a apresentação de razões finais escritas (fls. 283/285). O Ministério Público ofereceu seus memoriais às fls. 289/302, ratificando os termos da denúncia, aduzindo, contudo, que os fatos contidos na exordial melhormente se adequariam ao furto qualificado por concurso de pessoas e por fraude, pedindo desde já a aplicação da emendatio libelli. Requereu a exasperação da pena primeira fase pelo profissionalismo e pelo fato de não ter havido devolução dos valores pelas instituições financeiras à vítima, além desta se tratar de pessoa que era idosa e estava com câncer em estágio terminal, de modo que a pena-base deveria ser duplicada ou triplicada. Pediu o agravamento da pena na segunda fase, ante o estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19. E, no caso de se entender pela ocorrência do estelionato, pugnou pela incidência da causa de aumento do § 4º do art. 171 do Código Penal. Finalmente, solicitou a aplicação do regime inicial fechado, sem a possibilidade de substituição por penas restritivas de direito ou por sursis. A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais às fls. 306/308, aduzindo não haver elementos que liguem o réu ao delito, motivo pelo qual requereu sua absolvição ou, ao menos, a aplicação da pena no mínimo.

Após, os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDIDO.

Inexistentes preliminares ou nulidades a serem sanadas, passo diretamente ao julgamento.

A pretensão acusatória é improcedente.

Isso porque, embora a materialidade esteja demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelos documentos de fls. 115/121 e pela prova oral, colhida tanto na fase policial como em contraditório, a autoria é incerta.

A vítima somente foi ouvida na fase policial por ter falecido no decorrer da instrução, impossibilitando a tomada de seu depoimento em juízo.

Alegou a vítima ao delegado ter recebido uma ligação, na qual seu interlocutor se disse funcionário da CEF e informando terem sacado R\$ 1.500,00 de sua poupança, orientando-a ligar na ouvidoria, no número constante do verso do cartão. Disse ter sentido atendida por Paulo Augusto, o qual, então, lhe perguntou se dispunha de mais cartões para que ele pudesse cancelá-los também, pedindo para que os cortasse e conservasse apenas os últimos quatro dígitos e lhe fornecesse as senhas. Aduziu que Paulo Augusto lhe falou que um mensageiro denominado Tiago Silva iria até a sua casa para pegar esses cartões cortados e uma carta de próprio punho para que fosse viabilizado o ressarcimento do suposto saque fraudulento, o que ocorreu por volta das 16h30min. Sustentou que somente se deu conta de que havia caído em um golpe quando recebeu uma mensagem das Lojas Pernambucanas, pelo aplicativo do cartão, dizendo-lhe que haviam feito uma despesa de R\$ 2.750,00, razão pela qual entrou em conta com a ouvidoria da CEF, que confirmou nunca ter entrado em contato consigo. Asseverou ter cancelado todos os cartões, mas não sem antes os fraudadores terem gastado R\$ 500,00 com o do Banco Sicoob. Por fim, confirmou que, na delegacia, reconheceu por fotografia o réu, como a pessoa que foi à sua casa retirar os cartões e usando o nome de Tiago Silva (fls. 19/20).

Em juízo, foram colhidos os depoimentos de cinco testemunhas, conforme anotações deste magistrado:

ERIC LINI: Na verdade, eu não estava com a minha mãe nesse dia. Quem estava morando na cidade junto com a minha mãe é a minha irmã e ela tem os detalhes do fato ocorrido. Até o que eu sei, o RAFAEL veio até a casa da minha mãe, pegou o cartão e a senha dela, se aproveitou da situação e sacou o dinheiro. Eu não acompanhei a minha mãe na delegacia, porque hoje eu sou morador da cidade de Piratininga e, quando ocorreu o fato, eu não estava morando em Lençóis. Quem vai saber dizer quem foi que acompanhou a minha mãe até a delegacia é a minha irmã ELISANDRA. Eu e minha irmã somos testemunhas. O oficial levou os papéis para mim, e nesses papéis estavam o nome dela.

ELISANDRA LINI: Na verdade, eu não estava com a minha mãe na hora dos fatos. Eu estava trabalhando. Eu não morava com a minha mãe, mas ia todos os dias lá e nesse dia eu cheguei lá e ela estava muito nervosa porque ela tinha percebido que tinha sofrido esse golpe. Minha mãe me relatou que uma pessoa ligou para ela se passando pelo gerente do banco dela e falando que na conta dela havia sido debitado um valor e. que para eles poderem ressarcir a ela esse valor, eles precisariam do cartão dela e da senha. Depois, eles retornaram a ligação e perguntaram se ela teria conta em outros bancos, porque eles também precisavam do cartão e da senha para poderem verificar. Eles levaram o cartão da Caixa Econômica Federal, da Cooperserv, que é um banco da prefeitura, e um cartão de crédito da Pernambucanas. Eles fizeram compras no cartão da Pernambucanas, e depois nós conseguimos cancelar. Minha mãe não foi ressarcida pelo cartão da CEF nem foi ressarcida pelo valor que sacaram na Cooperserv. Na época, ela disse que foi um homem moreno que foi até o portão da casa dela, com uma moto, pegou os cartões e levou. Minha mãe foi muito inocente achando que era do banco e só se tocou depois, porque foi ver a conta, e estava zerada. Eu não fui com a minha mãe para ela fazer o reconhecimento. Foi um escrivão da delegacia que foi até a casa dela, porque minha mãe estava em tratamento de câncer e não podia sair de casa. Ele levou as fotos, e minha mãe reconheceu através das fotos. Eu não estava presente durante o reconhecimento. Minha mãe me contou que

tinha reconhecido a pessoa pela foto que o escrivão mostrou. O prejuízo na CEF foi mais de R\$ 6.000,00 e na Cooperserv foi por volta de R\$ 1.500,00. O boletim de ocorrência foi feito eletronicamente. Eu confundi. O Sicoob é o banco da prefeitura e o cartão da Pernambucanas é o que eles gastaram no crédito, mas nós conseguimos cancelar. Nós não conseguimos o ressarcimento do Sicoob nem da CEF. Eu não sei quantas fotos foram apresentadas para minha mãe, porque eu não estava presente no ato.

PC JÚLIO CESAR DE LIMA: A vítima registrou um boletim de ocorrência online pela Polícia Civil, e esse BO foi para mim. Nós já tínhamos o nome do autor, porque ele tinha se envolvido em uma situação análoga na cidade de Jaú, e nessa circunstância eu identifiquei o RDO e imprimi a foto. Eu compareci até a casa da vítima, e ela reconheceu fotograficamente e sem sombra de dúvidas o autor. Ela me narrou que foi ele que, com um nome falso, a procurou em seu imóvel para fazer o recolhimento dos cartões. A vítima compareceu até a delegacia, foi elaborada ordem de reconhecimento fotográfico, ela assinou e eu formalizei fazendo o relatório. No primeiro momento, eu fui até a casa dela, mas eu não me recordo se ela compareceu na delegacia. A vítima reconheceu o autor fotograficamente. Na data dos fatos, o réu se envolveu em uma situação de flagrante na mesma situação na cidade de Jaú e aqui em Lençóis ele tinha praticado dois crimes em situações idênticas a esses fatos. Eu mostrei a foto dele junto com outras, e, no caso ela o reconheceu. A pessoa que eu estou visualizando na audiência é a mesma pessoa da foto. Eu não conversei com o réu sobre os fatos, porque, na época, a Polícia de Jaú o prendeu em flagrante e ele foi removido para o CDP de Bauru, e eu não tive contato visual com ele. Eu apresentei a foto dele com mais uma ou duas pessoas do biotipo dele, porém, salvo engano, essa pesquisa que eu fiz com outras fotos, mas não foi juntada nos autos. Essas fotos foram despachadas em inquérito e não estão mais nas dependências do setor de investigação.

PC CLEITON GUILMO DE PAIVA: Aqui em Jaú ocorreu o seguinte: nós tivemos uma informação de que teria um indivíduo em uma agência do Banco do Brasil, com diversos cartões, realizando várias operações. Inclusive, nesse dia em que ele estava no banco, uma pessoa o reconheceu como sendo o indivíduo que, uma semana antes, havia ido à residência dela para pegar cartões. Nós fomos até a agência bancária, olhamos o sistema de monitoramento de câmeras, identificamos a pessoa, que estava com uma camiseta preta, calça jeans escura; a pessoa era negra e mancava. Munidos dessa informação, nós realizamos diligências nos hotéis da cidade, e em um desses hotéis nós encontramos a pessoa, o RAFAEL. O RAFAEL trazia com ele cartões, máquinas de cartão, o valor de R\$ 1.000,00 e papéis. Questionamos ao RAFAEL sobre os papéis e cartões e falamos sobre o golpe que houve na cidade, e ele acabou confessando. Um dos cartões que ele estava carregando com ele era de Claudete Branca Leão, uma das vítimas. Ele havia pegado o cartão de crédito e realizado diversos saques no nome dela. Ela ficou sabendo através de uma ligação do gerente dela. Inclusive, quando nós prendemos o RAFAEL, ela estava indo à delegacia para registrar o boletim de ocorrência. O golpe dele baseava-se em uma pessoa que falou que era mulher do Nigeriano, entrava em contato com as vítimas, e nesse contato a mulher se passava por uma funcionária da Polícia Civil ou funcionária da receita federal e informava que a vítima estava caindo em um golpe, mas na verdade era a mulher que estava aplicando o golpe. Nessa ligação, ela pedia as informações da pessoa, como endereço, cartão de crédito e a senha, e avisava à vítima de que uma pessoa iria até a residência, pediria para deixar os cartões dentro de um envelope lacrado e só deveria entregar para a pessoa que mostrasse um crachá e um código. Essa mulher passava esse código para a vítima. Nisso, entra o papel do RAFAEL: ele ia até a residência das pessoas, se passava por outra pessoa e tinha um crachá da Febraban e com o número "135". A vítima acabava entregando os cartões para o RAFAEL. Quando ele estava munido desses cartões, ele fazia saques, compras, empréstimos e tudo o que dava para fazer, porque a pessoa que ligou já tinha colhido a senha dos cartões da vítima. O Nigeriano, de São Paulo, tentava obter empréstimos em bancos. Essa vítima que estava na delegacia passou pelo

reconhecimento pessoal e o acabou reconhecendo como a pessoa que foi à casa dela buscar os cartões. A outra vítima, que avistou o Rafael no banco, também reconheceu o Rafael. O RAFAEL confessou e explicou toda a história, confirmou que tinha outras pessoas da cidade de São Paulo que trabalhavam com ele, mas não conseguimos identificá-las. Com os cartões da Claudete, o RAFAEL conseguiu fazer um saque de R\$ 1.000,00, realizou uma compra de R\$ 500,00 e um empréstimo de R\$ 1.000,00, ou seja, a Claudete teve um prejuízo de R\$ 2.500,00, e foram devolvidos R\$ 1.000,00 para ela. Com outra vítima, Paulo Renato Manuel, foi feito um empréstimo de R\$ 8.000,00, um saque de R\$ 4.232,00, um saque de R\$ 1.450,00 e outro saque de R\$ 3.000,00, cada um em uma agência. Eu não me recordo se foram apreendidos os cartões da NORMA. O flagrante aconteceu em 14/07/2020, em Jaú, e o caso do Paulo ocorreu em 09/07/2020. Eu acredito que a pessoa que eu estou vendo na tela seja o autor. Nós chegamos a identificar só essas duas vítimas aqui em Jaú, mas nós tomamos conhecimento de outras duas vítimas, mas, por vergonha, elas não quiseram registrar ocorrência. A minha parte da investigação parou no flagrante; então, eu não sei se foram realizadas novas diligências.

PC HENRIQUE VOLPI: Em relação a esses fatos apurados na comarca de Lençóis Paulista, eu não participei das diligências. Nossa equipe da delegacia de Jaú prendeu o investigado no hotel, sendo que, na data da prisão em flagrante, ele praticou o golpe em uma vítima. Ele integra uma organização criminosa com outros indivíduos, que é conhecida nos meios policiais como "Central Do Golpe", que é quando alguém liga na residência da vítima, se identifica como sendo funcionário do banco, diz que o cartão da pessoa foi clonado e que vai passar para um funcionário do banco realizar a coleta e pede para deixar a senha e demais dados. Na ocasião, o RAFAEL foi quem coletou um cartão aqui na cidade de Jaú, foi até a agência bancária, realizou o saque e foi preso em flagrante momentos depois desse fato. Além desse fato, uma semana anterior a esse crime, ele praticou contra uma outra vítima. Ele disse que vinha frequentando as cidades da região e fazendo esse tipo de coleta de cartão. No dia da prisão em flagrante, nós tentamos entrar em contato, mas essas vítimas não eram da cidade de Jaú, e então não conseguimos contatá-las. Além do cartão da vítima do flagrante, foram localizados outros cartões, maquininha de cartão e uma quantia em espécie, que era referente ao golpe aplicado na cidade de Jaú. Ele confessou que era responsável por realizar a coleta e ir até a agência realizar o saque ou passar os dados para outra pessoa da "Central do Golpe" e poder fazer compras online e obter vantagens. Eu não me recordo se tinha documentos ou cartões da NORMA; sei que havia cartões, mas não me recordo do nome de quem era cada cartão.

O réu também foi ouvido, dizendo aproximadamente o seguinte em seu interrogado: Eu nunca fui a Lençóis Paulista e não conheço essa cidade. Eu não fui à casa dessa vítima para retirar esses cartões. Eu sofri um acidente de moto em 2010, e desde então eu não consigo mais andar de moto porque eu tenho um encurtamento de 4,5 cm na perna. Meu joelho não dobra, e eu ando mancando. Quando aconteceu esse fato em Jaú, eu fui de Uber. Eu nunca vi essa mulher na minha vida e nunca tirei nenhum cartão na casa dela. Em Jaú realmente fui eu: foi a primeira vez em que eu estava tentando fazer isso e fui preso. Eu estou preso pelo delito de Jaú. Eu fui à casa da Claudete de Uber, retirei o cartão e fui ao banco, mas uma vítima em que eu tinha dado o golpe estava dentro da agência do banco e me viu. Eu fiz as transações no banco, atravessei a avenida de Jaú, chamei o carro pelo aplicativo e fui para o hotel em que eu estava hospedado. Cheguei ao hotel umas 13h00min, e quando foram mais ou menos 17h30min, os policiais civis de Jaú invadiram o hotel e me prenderam em flagrante. Eu tinha duas máquinas da "Moderninha". Eu não conheço a NORMA nem fui para Lençóis Paulista. Eu nunca fui para essa cidade. No dia 01/07/2020, eu estava em São Paulo. Eu sou de São Paulo.

Pois bem.

A prova oral não indica elementos a superarem dúvida razoável sobre o autor do crime. Explica-se.

A única ligação efetiva entre o réu e o crime sofrido pela vítima é o fato de ela o ter reconhecido por fotografia, que lhe foi apresentada em sua casa pelo PC JULIO

CESAR DE LIMA, o qual estava munido da informação de que RAFAEL, oriundo de São Paulo/SP, era autor de estelionatos similares praticados em Jaú/SP, cidade próxima à de Lençóis Paulista. Isto é, sem qualquer evidência da observância das regras do art. 226 do Código de Processo Penal.

Em razão da morte da vítima, o reconhecimento - feito fora da delegacia de polícia, repise-se - não foi confirmado em juízo.

Entretanto, em que pese a riqueza de detalhes dos crimes praticados pelo réu em Jaú, descritos pelo PC CLEITON GUILMO DE PAIVA, o golpe sofrido pela ofendida, embora até sofisticado, não é incomum, sendo cotidianamente praticado por ardilosos que enganam vítimas idosas a fim de que elas entreguem seus dados e seus cartões sem maiores questionamentos da idoneidade dessas pessoas.

E, relativamente aos crimes de Jaú, confessados pelo réu aliás em audiência, pesa uma situação interessante: o réu é pessoa com deficiência em uma das pernas, o que foi crucial para o seu reconhecimento por uma das vítimas em uma agência bancária daquela cidade, conforme depoimento do PC CLEITON, tendo ele próprio confirmado ter um encurtamento de 4,5 cm em um dos membros inferiores.

Essa importante característica do réu, facilmente detectável por quem quer que o veja de perto, não foi mencionada pela vítima em momento algum das três

oportunidades em que depôs na Polícia Civil, seja na elaboração do boletim de ocorrência em 01/07/2020 (fls. 03/04), seja no auto de reconhecimento fotográfico em 03/08/2020 (fl. 08), seja no seu depoimento formal em 10/02/2021 (fls. 19/20).

A filha da vítima, ELISANDRA LINI, afirmou em juízo que sua mãe apenas lhe disse que um homem moreno foi até a sua casa pegar os cartões e a carta, sem fazer qualquer menção à deficiência do réu, que o obriga a claudicar.

O réu, como visto, negou ter sequer pisado na cidade de Lençóis Paulista.

Anote-se que é fato que o réu compunha uma organização criminoso que atuava para realizar tais crimes, mas, ainda que tal organização tenha também vitimado NORMA LINI, não seria absurdo que outros agentes desse grupo tenham perpetrado o delito nesta comarca. Outrossim, reitere-se que o golpe sofrido pela vítima é infelizmente comum pelo país afora.

Logo, resta apenas um precário reconhecimento fotográfico feito pela vítima e não confirmado em juízo, o que é insuficiente para um decreto condenatório, por não seguir as regras do art. 226, além de haver o empecilho do art. 155, ambos do Código Penal.

Quanto à necessidade de observância das regras do art. 226 do CPP, e o problema em não raras induções (ainda que de boa-fé) para o reconhecimento fotográfico de pessoas, veja-se recente julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que referido o artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva com base no exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser

visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

2. Necessário e oportuno proceder a um ajuste na conclusão n. 4 do mencionado julgado. Não se deve considerar propriamente o reconhecimento fotográfico como "etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal", mas apenas como uma possibilidade de, entre outras diligências investigatórias, apurar a autoria delitiva. Não é necessariamente a prova a ser inicialmente buscada, mas, se for produzida, deve vir amparada em outros elementos de convicção para habilitar o exercício da ação penal. Segundo a doutrina especializada, o reconhecimento pessoal, feito na fase pré-processual ou em juízo, após o reconhecimento fotográfico (ou mesmo após um reconhecimento pessoal anterior), como uma espécie de ratificação, encontra sérias e consistentes dificuldades epistemológicas.

3. Se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal é válido, sem, todavia, força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica. Se, todavia, tal prova for produzida em desacordo com o disposto no art. 226 do CPP, deverá ser considerada inválida, o que implica a impossibilidade de seu uso para lastrear juízo de certeza da autoria do crime, mesmo que de forma suplementar. Mais do que isso, inválido o reconhecimento, não poderá ele servir nem para lastrear outras decisões, ainda que de menor rigor quanto ao standard probatório exigido, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia e a pronúncia.

4. Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel. Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas três teses: 4.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 4.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 4.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

5. Na espécie, a leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, além da análise do contexto fático já delineado nos autos pelas instâncias ordinárias, permitem inferir que o paciente foi condenado, exclusivamente, com base em reconhecimento fotográfico realizado pela vítima e sem que nenhuma outra prova (apreensão de bens em seu poder, confissão, relatos indiretos etc.) autorizasse o juízo condenatório.

6. Mais ainda, a autoridade policial induziu a vítima a realizar o reconhecimento - tornando-o viciado - ao submeter-lhe uma foto do paciente e do comparsa (adolescente), de modo a reforçar sua crença de que teriam sido eles os autores do roubo. Tal comportamento, por óbvio, acabou por comprometer a mínima aproveitabilidade desse reconhecimento.

7. Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento. O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar

e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto.

8. Em verdade, o resultado do reconhecimento formal depende tanto da capacidade de memorização do reconhecedor quanto de diversos aspectos externos que podem influenciá-lo, como o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor (tempo de duração do evento criminoso), a gravidade do fato, as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos, aspectos geográficos etc.), a natureza do crime (com ou sem violência física, grau de violência psicológica), o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento etc.

9. Sob um processo penal de cariz garantista (é dizer, conforme aos parâmetros e diretrizes constitucionais e legais), busca-se uma verdade processualmente válida, em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes maior controle sobre a atividade jurisdicional.

10. Adotada, assim, a premissa de que a busca da verdade, no processo penal, se sujeita a balizas epistemológicas e também éticas, que assegurem um mínimo de idoneidade às provas e não exponham pessoas em geral ao risco de virem a ser injustamente presas e condenadas, é de se refutar que essa prova tão importante seja produzida de forma totalmente viciada. Se outros fins, que não a simples apuração da verdade, são também importantes na atividade investigatória e persecutória do Estado, algum sacrifício epistêmico, como alerta Jordi FerrerBeltrán, pode ocorrer, especialmente quando o processo penal busca, também, a proteção a direitos fundamentais e o desestímulo a práticas autoritárias.

11. Impõe compreender que a atuação dos agentes públicos responsáveis pela preservação da ordem e pela apuração de crimes deve dar-se em respeito às instituições, às leis e aos direitos fundamentais. Ou seja, quando se fala de segurança pública, esta não se pode limitar à luta contra a criminalidade; deve incluir também a criação de um ambiente propício e adequado para a convivência pacífica das pessoas e de respeito institucional a quem se vê na situação de acusado e, antes disso, de suspeito.

12. Sob tal perspectiva, devem as agências estatais de investigação e persecução penal envidar esforços para rever hábitos e acomodações funcionais, de sorte a "utilizar instrumentos para maximizar as probabilidades de acerto na decisão probatória, em particular aqueles que visam a promover a formação de um conjunto probatório o mais rico possível, quantitativa e qualitativamente" (Ferrer-Beltrán).

13. Convém, ainda, lembrar que as prescrições legais relativas às provas cumprem não apenas uma função epistêmica, i. e., de conferir fiabilidade e segurança ao conteúdo da prova produzida, mas também uma função de controlar o exercício do poder dos órgãos encarregados de obter a prova para uso em processo criminal, vis-à-vis os direitos inerentes à condição de suspeito, investigado ou acusado. Nesse sentido, é sempre oportuna a lição de Perfécto Ibañez, que divisa, na exigência de cumprimento das prescrições legais relativas à prova, uma função implícita, a saber, a de induzir os agentes estatais à observância dessas normas, o que se perfaz com a declaração de nulidade dos atos praticados de forma ilegal.

14. O zelo com que se houver a autoridade policial ao conduzir as investigações determinará não apenas a validade da prova obtida - "sem bons ingredientes não haverá forma de fazer um bom prato" (como metaforicamente lembra Jordi FerrerBeltrán) -, mas a própria legitimidade da atuação policial e sua conformidade ao modelo legal e constitucional. Sem embargo, conquanto as instituições policiais figurem no centro das críticas, não são as únicas a merecê-las. É preciso que todos os integrantes do sistema de justiça criminal se apropriem de técnicas pautadas nos avanços científicos para interromper e reverter essa preocupante realidade quanto ao reconhecimento pessoal de suspeitos. Práticas como a evidenciada no processo objeto deste writ só se perpetuam porque eventualmente encontram respaldo e chancela tanto do Ministério Público - a quem, como fiscal do direito (custos iuris), compromissado com a verdade e com a objetividade de atuação, cabe velar

pela higidez e pela fidelidade da investigação dos fatos sob apuração, ao propósito de evitar acusações infundadas – quanto do próprio Poder Judiciário, ao validar e acatar medidas ilegais perpetradas pelas agências de segurança pública.

15. Sob tais premissas e condições, não é possível ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova absolutamente desconforme ao modelo legal, sem a observância das regras probatórias próprias e sem o apoio de qualquer outra evidência produzida nos autos.

16. Ordem concedida, para absolver o paciente em relação à prática dos delitos de roubo e de corrupção de menores objetos do Processo n. 0014552- 59.2019.8.19.0014, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campos dos Goytacazes – RJ, ratificada a liminar anteriormente deferida, a fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso. (Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus nº 712.781/RJ. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Sexta Turma. DJe de 22/03/2022)

Logo, havendo dúvidas razoáveis de que o réu, ou mesmo seu grupo, tenham atuado nesta comarca, havendo apenas um reconhecimento fotográfico sem evidências de seu método, realizado fora da delegacia de polícia, e não confirmado em juízo, a absolvição é a única saída.

Non liquet de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória entabulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para ABSOLVER o réu RAFAEL DA SILVA ALVES DE JESUS do crime que lhe é imputado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Lencois Paulista, 27 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA